

1500475-10.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... havia denúncia anônima em relação ao tráfico de drogas e posse de arma praticados na residência do réu, o que motivou o início das investigações, inclusive, com registro de imagens e constatação de movimentação típica de tráfico de drogas.

A denúncia anônima foi materializada pelo documento de fl. 14, o que reforça a versão apresentada pela polícia, a justificar, junto aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1500475-10.2022.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500475-10.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153888/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 25411862 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 2153888 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

MURILO HENRIQUE DE ALMEIDA ASCENCIO

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de MURILO HENRIQUE DE ALMEIDA ASCÊNCIO, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 17h00, na Rua Manoel Ramos, nº 307, Conjunto Habitacional Ana Jacinta, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado guardava e tinha em depósito droga, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, consistentes em 01 (uma) porção de Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total aproximado de 4,17g (quatro gramas e dezessete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o denunciado possuía e mantinha sob guarda: (i) 01 (uma) arma de fogo (garrucha) de uso permitido, da marca Castelo, calibre nominal 320; (ii) 04 (quatro) cartuchos de munições de uso permitido, íntegros, da marca CBC, de calibre nominal 32 S&WL, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Segundo a acusação, o denunciado adquiriu a porção de droga acima descrita de terceira pessoa até o momento não identificada, guardou-a e deixou-a em depósito no interior da sua residência, com vistas a comercializá-la ilicitamente. Ademais, o denunciado também possuía e mantinha sob a sua guarda a arma e as munições de uso permitido supramencionadas.

De acordo com a denúncia, inicialmente, os policiais civis receberam a denúncia anônima nº 23/2022, no dia 01/06/2022, a qual indicava que "Murilo" realizava a venda de drogas em sua casa no período noturno e possuía arma de fogo. Em diligências prévias durante o período noturno, a equipe policial constatou que no local indicado pelo denunciante ocorria intensa movimentação típica de tráfico de drogas: pessoas chegavam em frente ao imóvel do denunciado, chamavam-no, inseriam a mão para dentro do portão e pegavam algo.

Continua, afirmando que alguns conferiam o que adquiriram e outros colocavam o objeto imediatamente no bolso e saíam rapidamente. No dia dos fatos, policiais civis dirigiram-se ao imóvel visado durante o período diurno e foram atendidos pelo denunciado que, indagado, admitiu ter arma de fogo e porção de droga em seu quarto. No cômodo indicado foi localizada 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido total aproximado de 4,17g, 01 (uma) arma de fogo (garrucha) de uso permitido, da marca Castelo, calibre nominal 320 e 04 (quatro) cartuchos de munições de uso permitido, íntegros, da marca CBC, de calibre nominal 32 S&WL. MURILO disse que guardava a arma a pedido de uma pessoa de prenome "Diego" e que a droga lhe pertencia.

Em audiência de custódia realizada aos 07 de junho de 2022, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva (fls. 39/45).

Denúncia recebida aos 07 de julho de 2022 (fls. 88/89).

Citado pessoalmente (fl. 103), o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual e requereu o benefício da justiça gratuita (fls. 147/151).

Por decisão de fls. 158/162, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, e houve deferimento da justiça gratuita.

Por decisão datada aos 05 de setembro de 2022, foi mantida a prisão preventiva do acusado (fl. 187).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado.

Em seus memoriais (fls. 222/234), o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado. Preliminarmente, alegou ilicitude da prova, ante a violação de domicílio pela polícia. No mérito, alegou ausência de materialidade delitiva quanto à posse de arma de fogo; atipicidade da conduta em relação às munições; ausência de provas quanto ao delito de posse de arma de fogo e munições. Pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo próprio; bem como a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando, e substituição da pena privativa por restritiva de direito (fls. 237/259).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, no que se refere à preliminar suscitada pela defesa técnica, de rigor a rejeição.

Conforme será melhor detalhado na fundamentação abaixo, as testemunhas policiais foram uníssonas em afirmar que havia denúncia anônima em relação ao tráfico de drogas e posse de arma praticados na residência do réu, o que motivou o início das investigações, inclusive, com registro de imagens e constatação de movimentação típica de tráfico de drogas.

A denúncia anônima foi materializada pelo documento de fl. 14, o que reforça a versão apresentada pela polícia, a justificar, junto aos demais elementos apontados, a autuação do flagrante.

Neste caso, está-se diante de distinguishing, se considerados os precedentes

citados pelo nobre defensor.

Com efeito, já pacificou o C. Supremo Tribunal Federal:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/R0, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 - repercussão geral - Tema 280 - Info 806 - destaquei).

No caso em tela, os policiais justificaram a diligência, apresentando fundadas razões para a ação do flagrante, consistente na reunião de indícios de materialidade colhidos durante as investigações, após terem recebido denúncia anônima que noticiava o tráfico de drogas e posse de arma pelo réu.

Convém mencionar, quanto à alegação de que a investigação teria que ter sido filmada, que é cediço que a captação de vídeo depende da tecnologia dos aparelhos disponibilizados à polícia, de maneira que deve ser relativizada tal exigência, que, em verdade, se afigura recomendável apenas, ainda mais no caso dos autos em que o réu foi flagrado na posse de drogas, arma e munições, tendo admitido isso, além de ter dito em solo policial que franqueou a entrada da equipe policial e que a ação desta ocorreu "no mais absoluto respeito" (fl. 06).

Quer dizer, os depoimentos dos policiais e o interrogatório inquisitorial contradizem a versão passada pelo réu em juízo, de que a polícia foi logo chegando e adentrando sem qualquer autorização, sendo que, sob outro viés, corroboram a informação de que o réu realmente foi interpelado e autorizou a entrada. Neste caso, está-se diante de distinguishing, se considerados os precedentes citados pelo nobre defensor, pois constatada versão mendaz do acusado em juízo, nesse particular.

Como consequência, não há falar em ausência de justa causa para o deslinde da ação penal, ou mesmo incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada: pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01/02); pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12); pelo auto de exibição/apreensão (fls. 13); pelos laudos periciais (fls. 69/71, 78/82 e 104/136); bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A autoria é certa e incide sobre o réu.

Andrews Markus Bratfisch, policial civil, ouvido em juízo na condição de testemunha, disse que chegou denúncia apócrifa no dia 01º de junho informando que um rapaz do bairro Ana Jacinto, com apelido "Português", estaria realizando traficância. Esse rapaz teria ficado alguns anos fora do país e estaria em uma residência morando sozinho. A denúncia ainda relatava que o rapaz aludido possuía uma arma de fogo. Diante disso, realizaram monitoramento, mas não foi possível fazer a captura de imagens, pois estavam com outra investigação. Chegou a fazer fotografias e havia movimentação de pessoas no portão da residência. A denúncia narrava que o delito era perpetrado no período da noite. Conseguiu visualizar a chegada e saída de pessoas. Houve relatos que o indivíduo teve uma briga. Abordado, o réu admitiu que tinha uma arma, mas não seria dele, apontando que estaria dentro do guarda-roupas. Outro policial localizou a arma de fogo e a porção de droga. Sobre o fato de o réu enterrar drogas, ele admitiu que realmente fazia isso. O próprio réu havia dito que adentrou em um terreno nas proximidades, visto que não deixava "droga em cima". O réu disse que era usuário e a droga não era dele. O réu alegou para a equipe policial que tinha dado uma festa e um rapaz teria deixado o entorpecente e o armamento junto com as munições. Disse para o réu na ocasião que receberam denúncia que ele estava com quilos de drogas, ao que ele aduziu que não procedia essa informação. No quintal do réu havia escavação próximo ao pé de bananeira que lá se localizava. O réu disse o nome da pessoa que lhe entregou a arma. No imóvel não havia nada que indicasse ter ocorrido uma festa. A denúncia anônima era direcionada ao réu. Um outro investigado situava-se nas proximidades da residência do réu. Foi localizada uma porção de droga, que o réu apontou que estava

em seu guarda-roupas. O réu disse o nome de uma pessoa e alegou que fez uma festa com duas meninas e um rapaz, sendo que o entorpecente era destinado ao uso dessas pessoas.

Cezar Naim de Oliveira Wehbe, policial civil, ouvido em juízo na condição de testemunha, disse que atuou em apoio ao policial Andrews. Esteve presente no local dos fatos. Foram atendidos pelo denunciado. Indagou o réu se havia algo ilícito, ao que este respondeu que havia, no cômodo em que residia. Realmente havia uma porção de maconha, em quantidade pequena. Ao ser indagado, o réu disse que era sobre de 50,0 gramas que havia adquirido e enterrado no quintal dele. O réu disse que enterrou no fundo de sua casa. Foi até o quintal da residência e realmente viu que próximo do pé de bananeira a terra estava alterada. Em relação à arma, era uma garrucha pequena, com dois canos, bem como o réu também estava com quatro munições calibre 32, porém, a arma era de calibre diferente. Havia informação sobre a existência de uma arma calibre 38, porém, o réu alegou que passou por ele mas não lhe pertencia. O réu disse também que fez uma festa com duas garotas e um outro rapaz, sendo que este levou a arma calibre 38 e lhe mostrou. Na delegacia, a irmão do réu disse que ele tinha intenção de matar a ex-namorada e por isso adquiriu a arma. Esclareceu que a munição não "calçava" na arma, sendo que havia milímetros de diferença.

Interrogado em juízo, o réu Murilo Henrique de Almeida Ascêncio disse que estava com a arma, porém, não lhe pertencia. Estava com a arma há menos de 08 horas. Estava em uma festa, onde conseguiu trazer duas meninas para sua casa. Da sua casa, foi juntamente com um amigo à casa das meninas, que fica no bairro Ana Jacinta. De manhã iria fazer um frete. Ao irem embora, perguntou para o amigo se ele não iria pegar o "negócio" que deixou em sua residência, ao que aquele respondeu que "depois pegaria". Ao realizar o frete, ligou para o amigo e disse que iria levar a arma para ele, mas a polícia invadiu a casa e localizou a arma. Disse que prestou o mesmo depoimento na delegacia, mas não sabia a rua que o rapaz morava. Relatou que não forneceu o telefone do rapaz, pois tinha medo de represália. Em relação ao entorpecente, relatou que era de sua propriedade. Negou praticar a venda de maconha. Aduziu que nunca realizou venda de drogas. Alegou que trabalha realizando frete e de vez em quando conta com a ajuda de um rapaz. Sobre as mensagens averiguadas no seu celular, relatou que estava avisando os amigos que a polícia estava pressionando, mas que iria buscar ferro velho. Sobre as imagens coletadas no seu celular, relatou que as drogas pertenciam às pessoas que passavam em sua casa. Quando a polícia fez a diligência, estava no interior da casa. Quando se deparou, os policiais já haviam pulado para dentro e deram voz de prisão. Em momento algum deu autorização para que os policiais adentrassem. Afirmou que a droga era destinada ao seu próprio consumo.

Pois bem.

É cediço que no processo penal por tráfico/porte-posse de drogas e posse de armas/munições, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido, ainda:

VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,

por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência (HC73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). No caso dos autos, os policiais relataram, em essência, a apreensão da droga, da arma e das munições com o réu.

O réu, por sua vez, admitiu a propriedade da droga e a posse da arma e das munições, ressaltando, no entanto, que o entorpecente se destinava a seu próprio consumo e que a arma e as munições não lhe pertenciam.

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas, conferindo-se, pois, valor probatório aos depoimentos dos policiais.

Contudo, cabe uma ressalva.

Conquanto a denúncia tenha relatado que o entorpecente localizado destinava-se à entrega, pelo réu, a terceiros, não foi isso que se verificou.

Deve ser salientado que não havia nenhuma pessoa juntamente com o réu, a evidenciar que ele estaria a comercializar drogas no local.

Além disso, os policiais não presenciaram nenhum ato de mercancia, embora tenham dito que havia movimentação suspeita na residência do acusado.

A par disso, foram apreendidos apenas 4,17 g de maconha, ou seja, ínfima quantidade, que não se revela incompatível com o uso, mormente quando associada às demais circunstâncias do caso concreto.

Mais: não foi localizado com o réu, efetivamente, nenhum apetrecho à venda de drogas, como por exemplo saquinhos para embalagem do entorpecente e balança de precisão, tampouco dinheiro de qualquer monta.

O fato de terem sido localizados diálogos do réu com outros interlocutores, tratando da aquisição e possível repasse de entorpecentes, por si só, configurou apenas suspeita de que a maconha apreendida se destinava à mercancia, mesmo porque o tráfico propriamente dito não foi corroborado sob o crivo do contraditório, o que era imprescindível para a consumação e conseqüente condenação, à luz do que dispõe o art. 155 do CPP.

Ademais, tais diálogos ocorreram em data anterior àquela em que o réu foi preso por este processo, não havendo evidências de correlação lógica com o fato narrado na denúncia.

Nessa senda, valendo-se do disposto no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, levando em conta a pequena quantidade da droga, as circunstâncias em que foi apreendida, e a ausência de prova da mercancia, não se corrobora a tese de que esse entorpecente destinava-se ao tráfico.

Desse modo, aplicando-se no caso vertente o princípio in dubio pro reo, não há como condenar o acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Impõe-se, assim, a desclassificação delitiva, cabendo salientar que o próprio réu admitiu que é usuário de drogas e a conclusão que se chega por meio deste processo, portanto, é que o entorpecente apreendido era destinado ao consumo pessoal do acusado, sendo de rigor sua condenação como incurso no delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006.

No que tange à prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, além da materialidade e autoria terem sido corroboradas pelas testemunhas policiais, o próprio réu confessou que realmente guardou a arma e as munições em sua residência. A par disso, a prova técnica atestou a potencialidade lesiva atinente.

Concluiu a i. Perita:

"Seus mecanismos encontravam-se alinhados e articulados, portanto, aptos para serem utilizados. No entanto não foi possível realizar o teste de eficácia uma vez que não foi encaminhada munição compatível e este Núcleo de Perícias não dispõe de cartuchos deste calibre

(...)

Todos os cartuchos foram consumidos no teste de eficácia e funcionaram a contento, constatando-se que estavam aptos para serem deflagrados em arma de calibre compatível. Os componentes dos cartuchos não acompanham a garrucha devolvida para a autoridade requisitante" (fls. 80 e 82 - destaquei).

É válido recordar que o delito em questão possui a seguinte redação:

"Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa".

Assim, para a configuração do tipo penal em apreço, basta a prática de tais condutas sem a comprovação de autorização e em desconformidade com determinação legal ou regulamentar.

Apesar do inconformismo defensivo, a figura penal em apreço é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo, para sua configuração, a ocorrência do efetivo prejuízo à sociedade.

Nesse sentido:

"Posse ilegal de acessório ou de munição Apreensão de munição ou de acessório de uso permitido no interior de residência Tipo penal de perigo abstrato Entendimento do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 A apreensão de munição ou de acessório desacompanhados da respectiva arma não afasta a realização do tipo penal da posse ilegal de munição ou de acessório de uso permitido, uma vez que a potencialidade lesiva do objeto deve ser aferida de modo abstrato. Basta, assim, para o reconhecimento do crime o simples fato de o agente ter sido flagrado ocultando e mantendo aludida munição ou referido acessório sob sua guarda, sendo irrelevante a circunstância de estarem eles acompanhados ou não da correspondente arma de fogo. (...) Com relação ao delito de posse ilegal de munição de uso permitido, não há que cogitar-se de atipicidade da conduta, em razão ausência de potencialidade lesiva. No laudo pericial de fls. 16/17, com efeito, constatou-se que: 'As peças acima descritas encontram-se aptas para uso em arma de fogo' (fls. 17). Ressalte-se, ainda, que, não havendo nenhum indício de que o acusado pretendia entregar a munição (como, por exemplo, se tivesse apresentado a exigida guia de trânsito expedida pela Polícia Federal, ou órgão por ela credenciado, consoante o art. 70, parágrafo 1º, do Decreto n. 5.123/04), nos termos do art. 32 da Lei n. 10.826/03, não há como presumir-se a sua boa-fé, sendo a conduta perpetrada típica. (...)". (TJSP, Apelação nº 0002235-86.2012.8.26.0270, Rel. Grassi Neto, j. 06/08/2015 - destaquei).

Registre-se que os tipos penais contidos na Lei nº 10.826/03, que revogou a Lei nº 9.437/97, objetivam a garantia e a preservação do estado de segurança, a integridade corporal, a vida, a saúde e o patrimônio de todos os cidadãos, indefinidamente considerados, contra possíveis atos que os exponham a perigo. Como dito, a simples realização de quaisquer das ações previstas no núcleo de um dos tipos penais contidos na lei basta para a consumação do crime.

É irrelevante qualquer avaliação subsequente sobre a ocorrência, no caso concreto, de efetivo perigo à coletividade, salvo se caracterizar delito mais grave.

Desse modo, o fato de as munições serem incompatíveis com a arma não elide a responsabilidade penal do acusado.

Nesse sentido, em caso parelho, deliberou o C. STJ:

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. PORTE DE MUNIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. 3. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENSADA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. 5. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Atento a essa evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar decisões no sentido de não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na

inicial no afã de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal. 2. A orientação firmada nesta Corte Superior é no sentido de que o porte de munição, ainda que sem arma, é conduta típica. Portanto, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo alinha-se ao entendimento sedimentado na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do HC n.º 97.256/RS, admitiu a possibilidade de substituição, como também de regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado, observadas a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação do princípio da individualização da pena, medida que seria compatível com a benesse concedida. Todavia, no caso em apreço, consoante preceituam os arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei de Tóxicos, ainda que a pena tenha sido arbitrada no total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a fixação do regime prisional mais brando não se mostra adequada, haja vista a natureza e a quantidade de droga apreendida - 10,48g (dez gramas e 48 centigramas) de cocaína acondicionados em 23 porções e 17,40g (dezesete gramas e quarenta centigramas) de maconha - em poder do paciente. Precedentes do STJ. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não tem cabimento, uma vez que não preenchido o requisito objetivo. 5. Ordem não conhecida". (STJ, HC 254.875/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 5ª Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013).

Não bastasse, no caso dos autos, o acusado estava na posse de arma, munição, e drogas (ainda que para consumo próprio), o que revela significativa potencialidade lesiva, apta a afastar qualquer alegação de incidência do princípio da insignificância.

Portanto, a prova é bastante para a condenação criminal do réu, valendo ressaltar que, no caso concreto, não ficou evidenciada nenhuma circunstância excludente de ilicitude ou culpabilidade a beneficiá-lo.

Dito isto, passo a dosar a pena do réu.

Quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, o réu é primário e, considerando o caso concreto, em que trazia consigo ínfima quantidade de maconha, entendo pertinente a aplicação da sanção mais branda, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas.

Quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, "caput", do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (trata-se de réu primário); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (nada especial a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo, em 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase da dosimetria penal, não incidem agravantes. De outro lado, incide a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária, contudo, em 01 (um) ano de detenção, tendo em vista que nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Assim, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa. Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois não há elementos sobre a capacidade financeira do réu que autorize a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

Feito um juízo de valoração da conduta do réu, verifico que a substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação do disposto no artigo 44 do Código Penal, demonstra-se adequada e suficiente para a repressão do delito, não havendo, então,

necessidade de mantê-lo no cárcere.

Assim, nos termos do artigo 44, § 2º, do CP, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, na forma a ser especificada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para:

(a) ABSOLVER o réu MURILO HENRIQUE DE ALMEIDA ASCÊNCIO, já qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas nestes autos a respeito da prática do delito descrito no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, o que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

(b) CONDENAR o réu MURILO HENRIQUE DE ALMEIDA ASCÊNCIO, já qualificado nos autos, por trazer consigo droga para fins de consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006), à sanção de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, I, da Lei 11.343/2006, e;

(c) CONDENAR o réu MURILO HENRIQUE DE ALMEIDA ASCÊNCIO, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 12 da Lei 10.826/2003, SUBSTITUINDO a pena privativa por restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, na forma a ser especificada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais. Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, por não estarem presentes os requisitos pertinentes, valendo ressaltar que lhe foi aplicada pena substitutiva e a situação fática é a mesma desde que deliberada sua soltura (fls. 205/206). Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, pois sequer houve debate a respeito da dita indenização, de modo a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, e diante da natureza difusa do sujeito passivo.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), ficando a exigibilidade do pagamento suspensa em razão da justiça gratuita (já deferida à fl. 160).

Com relação à arma e à munição apreendidas, proceda-se o envio ao Comando do Exército para os fins previstos no artigo 25 da Lei nº 10.826/03.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- 1) Atualize-se o histórico de partes;
- 2) Comunique-se o IIRGD;
- 3) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- 4) Restitua-se o celular apreendido ao réu;
- 5) Expeça-se guia de execução definitiva.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA